

1500733-61.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... multirreincidência (fls. 36/37 – condenação por tráfico proferida pela 2º vara de Diadema, e também por tráfico pela 3º Vara de Diadema - fl. 63) donde agravo a pena em 1/5, valendo-me do princípio da proporcionalidade e para uma mais justa individualização da pena considerando a reiteração delitiva, perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa .

Em terceira fase, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500733-61.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000577

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102759/2022 - 03º D.P.

DIADEMA, 2102759 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gilberto Sposito Luchi

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

GILBERTO SPOSITO LUCHI, qualificado às fls. 09 e 16/17, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 13 de abril de 2022, por volta das 11h00, na Passagem do Progresso, altura do nº 206, Vila Nogueira, nesta cidade de Diadema, trazia com ele, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 24 embalagens plásticas contendo 14,4g da droga cocaína, 28 embalagens plásticas contendo 5,6g da mesma droga, na forma de crack, e 10 embalagens plásticas contendo 52g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 11 e laudo de constatação provisória de fls. 13/15, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.43/46), o réu foi notificado e citado (fls. 96 e 122), e apresentou defesa preliminar as fls. 89/91, através de Advogada constituída. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 18/05/2022 (fls.93/94).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas tempestivamente pelas Partes, e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, com a agravantes da multirreincidência, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem possibilidade de apelo em liberdade, mas sim com a perda do numerário apreendido.

Já a d. Advogada reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, reduzindo a pena e a substituindo com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl.11, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls. 13/15 e 84/86), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.7 e 8), realizaram diligência na Passagem Progresso, em Diadema, dentro de uma comunidade, local este conhecido pelo tráfico de drogas. Assim que se aproximaram do numeral 206, observaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo GILBERTO SPOSITO LUCHI que, por sua vez, vendia drogas no local. Observaram que GILBERTO, ao ser abordado por algum comprador, ia até um cano de PVC localizado na casa de número 206, onde se encontrava uma sacola preta, retirava os entorpecentes de dentro desta e repassava aos compradores. Por tal razão, abordaram GILBERTO, que os levou até a sacola preta que se encontrava no cano acima mencionado, que continha em seu interior: a quantia de R\$93,00; 10 porções de substância aparentando ser maconha; 28 porções de substância similar à crack; e 24 porções de substância semelhante à cocaína. Diante do exposto, conduziram a ocorrência para essa unidade policial.

Sob o crivo do contraditório o policial Ricardo Oliveira alegou que o local é conhecido pela equipe como ponto de venda de entorpecente. Realizaram campanhas, e no dia dos fatos observaram movimentação típica de tráfico. Avistaram o réu. Usuários chegavam, ele ia num cano de água, pegava algo, um objeto preto, e fazia transação com o usuário, que ia para o lado contrário, sentido escadão. Observaram se a drogas estavam com ele ou onde ele guardava, e assim que souberam, desceram e o abordou. O réu estava de frente para o cano e não confessou a autoria do tráfico, mas apontou onde as drogas poderiam estar, e assim que colocou a mão dentro do cano, não conseguiu acessar, e acha que por isso ele tenha indicado, porque não encontrou na primeira vez, mas depois viu que tinham uns pedaços de cano quebrados,

e por ali conseguiu puxar uma sacola e ali dentro estavam as drogas (maconha, crack e cocaína) além de dinheiro em notas trocadas, e com o réu também tinha um pouco de dinheiro. Reconhece o réu. Já tinha visto o réu lá antes, dispersando com a chegada da viatura policial. Às reperguntas da Acusação, viu o réu fazer um ato de venda de droga. Não se recorda de algum parente do réu ter se aproximado quando da detenção. O réu ficava olhando muito para baixo, e era uma rua íngreme. Foram abordadas outras duas pessoas num bar próximo de onde o réu estava, porque havia notícia de que seriam os abastece.

Igualmente o policial José Antonio dos Santos alegou que o local é conhecido por venda de entorpecente. Ficaram no local fazendo campana por uns dez minutos. Havia uma certa aglomeração. Quando uma pessoa ia numa certa altura da rua, pegava algo no cano de PVC de água. Ele serviu a pessoa que foi até ele. Então o abordaram. Localizaram o entorpecente. Reconhece o réu, e não o viu lá antes. A princípio o réu negou, mas depois, informalmente, ele lhe disse que estava ali traficando mesmo. Foram apreendidos 10 trouxas de maconha, 28 pedras de crack e 24 invólucros cocaína, além de dinheiro, uns noventa reais. Ninguém se aproximou da equipe quando da prisão do réu. O réu estava numa viela, e tem um bar um pouco mais para baixo de onde ele estava. No mesmo dia prenderam mais duas outras pessoas.

A testemunha de defesa Elenilda Gomes disse que o réu estava no beco, carregando areia, como servente de pedreiro, e ele foi enquadrado com mais dois rapazes. Não viu ele ser pego, só quando o trouxeram para o seu bar, e não viu ele com nada. Acharam um pacote do outro lado da rua. Os outros dois rapazes que também foram detidos e não estavam com nada. Na viela sempre tem obra, porque caminhão não entra lá, tem que carregar areia lá para dentro. Não viu os policiais com nada quando eles levaram o réu para dentro do bar, nem com os três rapazes. A sacola que foi achada pelos policiais estava num cano do outro lado da rua. Estava atrás do balcão quando viu os policiais acharem o pacote dentro de um cano da casa de uma vizinha, Sra. Zilda, e não sabia o que tinha dentro.

A testemunha de defesa Maria Raelly disse ter visto a prisão do réu porque tinha acabado de ir na padaria. Ele saiu de dentro do bar e ido na casa de uma senhora que venda lanche na viela. Chegou o carro com os policiais que pegaram ele na viela e levaram para o bar na frente da padaria onde ela estava. Ele não estava com nada. Depois um policial foi até um cano e tirou uma sacola preta.

O réu, em solo policial (fl.09) preferiu calar-se.

Em juízo o acusado alegou estar sendo vítima de preconceito. Já teve problema com a justiça. Tem família, estava trabalhando como servente de pedreiro, reformando uma casa que fica numa rua estreita e sempre carregando areia e tijolo. Suas testemunhas de defesa acompanham esse seu trabalho. Foi comprar refrigerante e ao sair da viela vieram os dois policiais e perguntaram sobre o local do tráfico, e disse que não sabia, e quando souberam que ele estava assinando sua condicional, foi levado para um bar onde já estavam outras pessoas. Não acharam nada consigo e por estar sem documento, foi levado ao DP. Trabalha para o Antonio, que mora perto da casa de sua sogra, há três meses, pagando oitenta reais por dia. Não trouxe essa pessoa para ser sua testemunha porque não está tendo contato com sua esposa e sua mãe não tem condições de ver isso. Já foi processado por tráfico. Às reperguntas, disse que lhe levaram para um bar onde estavam mais dois rapazes detidos. Não viu drogas nem no local nem no DP, não lhe mostraram nada até hoje.

Logo, os testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu optou pelo silêncio em solo policial, e sua negativa de autoria tardia além de não vir devidamente demonstrada, não é crível, e se verdadeira fosse, o normal

seria ele já ter trazido a mesma versão desde sede pré-judicial, inclusive porque na ocasião, segundo ele, o rapaz que trabalhava consigo na obra de reforma de um sobradinho, estava lá, e já poderia ter sido indicado para corroborar seu alibi e, inclusive, servir de sua testemunha, e não somente depois que teve tempo e condições de amadurecer versão mais satisfatória aos interesses da Defesa particular, que optou por trazer duas testemunhas que teriam visto o réu no ponto de venda de drogas, mas foram contraditórias entre si, e sequer foi arrolado o Sr. Antonio, justamente a pessoa que contratara o réu para trabalhar ali, como servente de pedreiro. E embora as testemunhas de defesa tenham dito que o réu não portava nada consigo, isso ocorreu porque as drogas estavam escondidas num cano.

No mais, ressalto o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Não bastasse isso, os policiais sempre afirmaram que o réu, por eles reconhecido, era o indivíduo parado, sozinho, na biqueira já conhecida como ponto de tráfico de drogas, e era procurado pelos usuários e lhes entregava as drogas que pegava de dentro de um cano de PVC, tanto que ali, posteriormente, apreenderam os narcóticos que, periciados, constatou-se tratar-se de crack, cocaína e maconha, além da quantia em dinheiro apreendida, cuja procedência lícita nem o réu nem a Defesa lograram êxito em demonstrar, pois como já dito, o Sr. Antonio, contratando do réu, não foi arrolado como testemunha. Não bastasse isso, os policiais fizeram campanha por uns dez minutos e efetivamente visualizaram o acusado, por eles reconhecido, em atos de venda de narcóticos a usuários, indicativo de que o numerário apreendido é proveniente da venda ilícita dos entorpecentes.

Quanto aos relatos das testemunhas de defesa, anoto mais uma vez, que Raelly é esposa de um dos dois rapazes que foi preso juntamente com o réu, na prática de tráfico, de modo que sua versão deve ser tida com reservas, assim como a versão da testemunha Elenilda, dona do bar onde esses dois rapazes foram presos, a indicar sua proximidade com eles. Não bastasse isso, os relatos dessas duas testemunhas foram contraditórios, dado que uma disse que o réu estava carregando areia quando foi detido, e a outra que ele foi detido ao sair do bar onde comprou uma bebida e se dirigia à viela para comprar um lanche.

As circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar, ter em depósito, e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (62 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a apreensão de numerário proveniente das vendas de drogas (fl.42) são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a quantidade de substâncias entorpecentes apreendida (62 no total) o que não reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do

salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, ausente circunstância atenuante, dado que o réu não confessou o crime nem em solo policial, menos ainda em juízo, nem se mostrou arrependido ou colaborou com a busca da verdade real. Presente a circunstância agravante da multirreincidência (fls. 36/37 - condenação por tráfico proferida pela 2º vara de Diadema, e também por tráfico pela 3º Vara de Diadema - fl. 63) donde agravo a pena em 1/5, valendo-me do princípio da proporcionalidade e para uma mais justa individualização da pena considerando a reiteração delitiva, perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa .

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente específico, a indicar que faz do crime seu meio de vida, tanto que apreendido dinheiro a não deixar dúvida da traficância, de modo que inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente é reincidente específico). Ademais: "Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, assim como a preponderância da natureza e da quantidade das drogas, crack e cocaína especialmente, de alto poder viciante e degradante da saúde humana, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de três meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC nº 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra GILBERTO SPOSITO LUCHI, qualificado às fls. 09 e 16/17, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 600 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Condene o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 Ufesp, nos termos da lei nº 11.608/03, ante a constituição de Advogada particular.

Decreto a perda de dinheiro apreendido (fl.11 e 42) em favor da União, que deverá ser transferido ao FUNAD, com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas e a destruição do objeto (fl.11 e 88).

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA